

第49問

甲が自宅で休んでいたところ、Aが新聞の集金のために甲宅を訪れた。甲は、この時、給料日前ということもあり、一文無しであったため、何とか集金を免れようと思い、Aに対して、「先日、ほかの方が訪れたので、その時に払いましたよ。」などと嘘をついた。すると、Aが、「そうでしたか、すみません。一度、事務所に戻って確認してみます。」と言い、その場を後にしたため、甲は、再度Aが集金に現れるのを恐れ、外出した。なお、Aが事務所で確認したところ、集金の記録がなかったことから、Aは、数日後、改めて甲宅へ集金に行き、甲から新聞代の交付を受けた。

その後、甲は、食事をしようと考え、定食屋へ入り、店主であるBに対して、「かつ丼ください。」と言い、かつ丼を注文した。Bは、これに応じ、かつ丼を作って、甲に交付した。甲は、かつ丼を食べている最中に、自分が一文無しであったことを思い出したため、かつ丼を食べ終わった後で、Bに対し、「友達が近くまで来ている。ちょっと迎えに行ってもいいか。」などと言ったところ、Bがこれを承諾した。そこで、甲は、定食屋を出た後、走ってその場から逃走した。

無銭飲食に成功したことで気分を良くした甲は、近所を散歩していたところ、Cが自己の自転車の後部の車輪を点検しているのを見つけた。そこで、甲が「どうしましたか。」とCに話しかけると、Cは、「車輪に木の枝が引っかかってしまって取れなくなってしまったのです。」と言った。甲が確認すると、簡単に取れそうだったが、Cの自転車が気に入り、これを欲しくなったため、「一度、自転車を解体しないと取れないでしょうね。工具はありませんか。持ってきてくれたら、私がやりましょう。」と言った。そこで、Cは、工具を取りに、その場から50メートル離れた自宅へ向かった。甲は、CがC宅内へ入って行ったところを確認すると、車輪から木の枝を取り、自転車に乗って、自宅へと帰った。

甲の罪責について、論じなさい。

第1 Aに対して、「先日、ほかの方が訪れたので、その時に払いましたよ。」などと嘘をつき、新聞代の集金を一時免れた行為

詐欺利得罪（246Ⅱ）の成否に関し、「財産上……の利益」を得たといえるかが問題となる（**論点**「財産上……の利益」（246Ⅱ）の意義）。

総合 219 頁 論証 99 頁

この点について、判例（最判昭30.4.8【百選Ⅱ57】）は、「すでに履行遅滞の状態にある債務者が、欺罔手段によって、一時債権者の督促を免れたからといって、ただそれだけのことで、刑法246条2項にいう財産上の利益を得たものということはできない。その際、債権者がもし欺罔されなかったとすれば、その督促、要求により、債務の全部または一部の履行、あるいは、これに代りまたはこれを担保すべき何らかの具体的措置が、ぜひとも行われざるをえなかったであろうといえるような、特段の状況が存在したのに、債権者が、債務者によって欺罔されたため、右のような何らかの具体的措置を伴う督促、要求を行うことをしなかったような場合にはじめて、債務者は一時的にせよ右のような結果を免れたものとして、財産上の利益を得たものといえることができるのである。」としており、単に債務履行の一時猶予を受けただけでは足りず、債権の財産的価値が減少したことが必要であるとしている。

甲は、新聞代の支払を一時的に免れたものの、Aは事務所で集金記録を確かめることにより甲が新聞代を支払っているかを確認することが容易であるし、住所等を了知しているAが甲に支払を求めることも容易であるから、債権の財産的価値が減少したとはいえない。

したがって、上記利益は「財産上……の利益」には当たらないから、詐欺利得罪は成立しない。なお、欺罔行為は「財産上……の利益」に向けられる必要があるから、虚言を述べるだけでは、詐欺未遂罪すら成立しない。

第2 Bの定食屋で無銭飲食をした行為（**論点** 無銭飲食）

総合 230 頁 論証 106 頁

- 1 かつ丼を頼んだ際には、支払意思がなかったわけではないから、1項詐欺罪（246Ⅰ）は成立しない。
- 2 そこで、2項詐欺罪の成否を検討することになる。本問では、「友達が近くまで来ている。ちょっと迎えに行ってもいいか。」などと言い、Bがこれを承諾しているため、この承諾が処分意思に基づく処分行為といえるかが問題となる（**論点** 詐欺罪における処分意思（交付意思）の内容 ■ 旧H6-2）。

総合 221 頁 論証 102 頁

甲が店外に出て、戻ってこなければ、代金の回収が著しく困難になることが明らかであるところ、Bは、甲に対して、代金支払を免除する意思は有していない。この点について、被欺罔者に自己が交付する利益の認識を要求するような判例（最決昭30.7.7【百選Ⅱ53】）がある一方（同判決は、「詐欺罪で得た財産上不法の利益が、債務の支払を免れたことであるとするには、相手方たる債権者を欺罔して債務免除の意思表示をなさしめることを要するものであって、単に逃走して事実上支払をしなかっただけで足りるものではないと解すべきである。されば、原判決が『「無銭」飲食、宿泊をなした後、自動車で帰宅する知人を見送ると申聞いて被害者方の店先に立出でたまま逃走したこと』をもって代金支払を免れた詐欺罪の既遂と解したことは失当であるといわなけ

ればならない。」と判示している。もっとも、同判決は、「逃亡前すでにAを欺罔して、代金32290円に相当する宿泊、飲食等をしたときに刑法246条の詐欺罪が既遂に達したと判示したものと認めることができる。されば逃走して支払を免れた旨の判示は、本件犯罪の成立については結局無用の判示」であるとしているから、上記判示部分は傍論である。）、学説上は、利益の外形的移転の認識があればよいというのが通説である。

第3 Cが工具を取りにC宅内へ入っていったところを確認すると、車輪から木の枝を取り、自転車に乗って、自宅へと帰った行為

この点については、処分行為（及びそれに向けられた欺罔行為）が認められるかが問題となる。

本問の場合には、そもそも、被欺罔者であるCに処分行為がない（処分意思がない。）と考えられるから、それに向けられた欺罔行為も認められない。

したがって、甲には、詐欺罪ではなく、窃盗罪（235）が成立する（**論点** 欺く行為と財産的処分行為との関係  旧H22-2）。

 217 頁  101 頁

答案構成

第1 Aに対して、「先日、ほかの方が訪れたので、その時に払いましたよ。」などと嘘をつき、新聞代の集金を一時免れた行為

1 2項詐欺罪（246Ⅱ）の成否

↓

2 債務の一時的猶予は、「財産上……の利益」に当たるか

↓

否定説（債権の財産的価値の実質的な減少が必要）

↓

あてはめ

↓

3 詐欺利得罪は成立しない

第2 Bの定食屋で無銭飲食をした行為

1 1項詐欺罪（246Ⅰ）不成立

↓

2 2項詐欺罪の成否

↓

処分行為（処分意思）の内容

↓

利益の外形的移転の認識があれば足りる

↓

3 あてはめ

↓

4 2項詐欺罪成立

第3 Cが工具を取りにC宅内へ入って行ったところを確認すると、車輪から木の枝を取り、自転車に乗って、自宅へと帰った行為

1 1項詐欺罪の成否

↓

2 処分行為（に向けられた欺罔行為）なし

↓

3 窃盗罪（235）成立

第4 罪数

2項詐欺罪と窃盗罪は併合罪（45）となる

第1 Aに対して、「先日、ほかの方が訪れたので、その時に払いましたよ。」などと嘘をつき、新聞代の集金を一時免れた行為

1 かかる行為について「人を欺いて」（246条1項）「財産上不法の利益を得」として、詐欺利得罪（246条2項）の成立が考えられる。

もっとも、甲は虚言によって、債務の履行を一時的に免れたにすぎない。このような利益は、「財産上……の利益」に含まれるか。

2 「財産上……の利益」とは財物以外の財産的利益一切をいい、債権・担保権の取得、労務の提供などの積極的利得のほか、債務免除や支払猶予を得るなどの消極的利得をも含むと解される。

そして、「財産上……の利益」を得たというためには、単に債務履行の一時猶予を受けただけでは足りず、債権の財産的価値が実質的に減少したことが必要である。「財産上……の利益」を得たというためには、財物の移転と同視し得るだけの具体性・確実性が必要だからである。

なお、債務履行の一時猶予にすぎないのか、債権の財産的価値が実質的に減少したのかは、債権者の事後的な追及の容易性によって変わり得る。

Aは事務所で集金記録を確かめることにより甲が新聞代を支払っているかを確認することが容易であるし、住所等を了知しているAが甲に支払を求めることも容易である。

現に、後日Aは甲から集金を行っていることから、上記各点が容易であったことがうかがわれる。

1

したがって、債権の財産的価値が実質的に減少したとはいえず、一時猶予にすぎないとみるべきである。

よって、上記利益は「財産上……の利益」には当たらない。

3 以上から、上記行為には、詐欺利得罪は成立しない。

第2 Bの定食屋で無銭飲食をした行為

1 まず、食事の交付を受けた行為につき、「人を欺いて財物を交付させた」として、1項詐欺罪（246条1項）が成立するか問題となる。かつ丼を頼んだときには支払意思はあったのであり、後から一文無しであったことに気づき、支払意思を失ったにすぎないから、故意（38条1項）を欠き、同罪は成立しないというべきである。

2 もっとも、支払を免れた行為につき、2項詐欺罪の成立が考えられる。

(1) 詐欺罪の成立要件として、処分行為が要求されるが、そこには主観的処分行為（処分意思）が含まれる。そして、処分意思があるといえるためには、少なくとも財産上の利益（財物の占有）の移転を基礎付ける外形的事実を被害者が認識していることが必要である。

それでは、さらに進んで処分意思の内容として被害者が移転する利益の内容・価値（交付した財物）を正確に認識していることが必要か。

(2) この点について、正確な認識が必要であると解する立場がある。しかし、このように解すると、相手方に移転する客体を認識させないという詐欺罪の典型を処罰することができない。

2

そもそも、処分意思に基づく処分行為の存在は、被欺罔者の瑕疵ある意思表示によって終局的に利益移転（財物の占有移転）がなされたか否かという意味において、不可罰な利益窃盗（対象が財物の場合には窃盗罪）との区別から必要な概念である。そうだとすれば、そのような区別ができるならば、その限度で移転する利益の内容・価値（交付した財物）についての正確な認識は不要である。

したがって、財産上の利益（財物の占有）の移転を基礎付ける外形的事実を被害者が認識している場合には、利益の移転（財物の移転）が被欺罔者の瑕疵ある意思表示によって終局的になされたと認められるから、たとえ財産上の利益（個々の財物）の内容を正確に認識していなくとも、処分意思を認めてもよいと解する。

3 本件では、Bは甲から友達を迎えに行くと言われているとはいえ、一度店外に出ることを許せば甲が代金を支払わず、逃亡する可能性は否定できず、債権回収が著しく困難になるおそれがある。

Bにはこのような事実の認識はあるだろうから、財産上の利益の移転を基礎付ける外形的事実をBが認識していたものと言える。

したがって、Bの瑕疵ある意思表示により、利益が終局的に移転したといえ、処分行為（処分意思）が認められる。

4 以上から、甲は、「人を欺いて」「財産上不法の利益を得」たものとして、2項詐欺罪が成立する。

第3 Cが工具を取りにC宅内へ入って行ったところを確認すると、車輪から木の枝を取り、自転車に乗って、自宅へと帰った行為

3

1 かかる行為につき、1項詐欺罪が成立するか。

詐欺罪は交付罪である以上、欺罔行為は処分行為に向けられたものである必要がある。そして、処分行為といえるためには、上記のように処分意思が必要であり、処分意思が認められるためには、少なくとも占有の移転を基礎付ける外形的事実を被欺罔者が認識していることが必要である。

2 本問の場合には、被欺罔者たるCが認識している外形的事実は「50メートル離れた自宅に行っている間に、甲が待っている」ことであり、これは占有の移転を基礎付ける外形的事実ではなく、占有の弛緩を基礎付ける外形的事実にすぎない。

したがって、被欺罔者たるCには処分意思が認められず、処分行為が観念し得ない。そうだとすれば、行為者の欺罔行為は処分行為に向けられたものではなく、本件行為者には詐欺罪は成立しない。

3 もっとも、被欺罔者の意思に反して占有を移転させている点で「他人の財物を窃取した」（235条）といえ、また、故意及び不法領得の意思に欠けるところもないから、窃盗罪の成立が肯定される。

第4 罪数

以上から、甲には、2項詐欺罪と窃盗罪が成立し、併合罪（45条）となる。

以上

4